

1501106-32.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luciana Castello Chafick Miguel

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... longe de um cenário conhecido como ponto de tráfico pela polícia, por vezes alvo de denúncia anônima por vizinhos.

O trabalho de investigação da polícia foi preciso, mormente quando o acusado já era figura conhecida dos meio policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes e as conversas do WhatsApp, com ofertas no sistema Delivery, confirmam sua dedicação a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

6ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos - SP - cep 11013-910

1501106-32.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501106-32.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON FAGUNDES DO NASCIMENTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Castello Chafick Miguel

Vistos.

anderson fagundes do nascimento, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26 de março de 2021, por volta das 8h, na Rua Doutor Emílio Ribas, nº 88, apto. 909, Vila Mathias, em Santos, guardava sete porções (uma grande do tipo tijolo e seis menores) da erva Cannabis sativa L (maconha) e dois comprimidos de ecstasy, drogas capazes de causar dependência psíquica e física, o que fazia sem autorização legal e regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito (fls. 1/2).

Laudo pericial do celular apreendido (fls. 211/279, 309/377)

Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 379/381 e 383/385).

O réu, devidamente notificado (fls. 289), apresentou defesa preliminar (fls. 202/209). A despeito dos argumentos invocados, a denúncia foi recebida em 05 de maio de 2021 (fls. 280/282).

Na audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e, ao final, o réu foi interrogado. Neste ato, a Defesa requereu a desistência da oitiva da testemunha Natasha Anastácia Gama Alves dos Santos, o que foi homologado pela Magistrada. Ainda, foi instaurado incidente de verificação de dependência química (fls. 403/405).

Houve impetração de Habeas Corpus, mas denegada a ordem (fls. 456/483).

O laudo pericial realizado nos autos do incidente de dependência toxicológica concluiu que: "Não foram identificados critérios para afirmação de transtorno mental e comportamental devido ao uso de substância psicoativa. Não há no histórico alegado dados sugestivos de quadros de abstinência ou intoxicações maciças, ou seja, as características elencadas no consumo de maconha do referido periciando não traduziram dependência moderada ou grave, mantendo sua funcionalidade mental, não interferindo em sua capacidade de autodeterminação." (fls. 77/82 dos autos em apenso).

Encerrada a instrução, os debates foram convertidos em memoriais, onde as partes sustentaram seus respectivos pontos de vista.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do réu no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, bem como requer seja determinada a destruição das drogas apreendidas, ressalvada a destruição a contraprova para após o trânsito em julgado. Quanto à pena a ser eleita, merece a pena-base majoração diante dos maus antecedentes evidenciados às fls. 66 e ss. O acusado já foi condenado pela prática do crime de tráfico, logo reincidente específico. Também por isso que, na terceira fase, o Ministério Público entende não ser possível a aplicação causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Tal benefício redutor se destina àquele traficante eventual e de pequena monta, que claramente não é o acusado, como bem ficou demonstrado. Este cenário, aliado à gravidade do crime em questão, que assola a sociedade, destrói famílias e fomenta toda a criminalidade, impõe o regime inicial fechado como medida razoável e adequada (fls. 511/521).

A Defesa, por sua vez, pediu que seja julgado improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado, nos termos do artigo 386, incisos I, II, V e VII do Código de Processo Penal, como medida de inteira justiça. Subsidiariamente, que seja desclassificada a imputação do artigo 33 da Lei de Drogas, para o artigo 28 da mesma lei, e então que seja anulado "ab initio" o processo nos termos do artigo 564, inciso I, do Código de Processo Penal, remetendo-se os autos para o Juizado Especial Criminal. Ainda, subsidiariamente, em caso de condenação, requer seja fixada a pena base no mínimo legal, afastando a majorante de maus antecedentes, considerada a atenuante da confissão e a minorante prevista no § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, com a fixação do regime aberto ou semiaberto, sendo aplicado o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, para a definição do regime inicial do acusado. Pede que seja concedido o direito de recorrer em liberdade e que seja concedido o pedido de Justiça Gratuita ao acusado (fls. 550/566).

É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 3/6), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/09), pelo auto de constatação preliminar (fls. 10), pelo laudo pericial do celular apreendido (fls. 211/279, 309/377), pelo exame

químico-toxicológico (fls. 379/381, 383/385), assim como pelas demais provas orais coligidas aos autos.

A autoria, por sua vez, é certa para sustentar um decreto condenatório.

Consta da denúncia: "Segundo se apurou, policiais civis investigavam esquema de comercialização de entorpecentes pelo "Disk Drogas", via aplicativos de comunicação e chamadas telefônicas. As investigações apontaram o denunciado como sendo traficante de drogas.

Isso gerou a expedição do mandado de busca e apreensão nos autos 1501043-

26.2021.8.26.0562, em trâmite pela 6ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP.

No dia do crime, os policiais realizaram diligência na residência do denunciado.

Com prévia autorização judicial, os policiais encontraram as porções de maconha que o denunciado guardava em uma gaveta da. Além disso, o denunciado tinha uma faca, tesoura, rolo de papel filme e balança de precisão, equipamentos próprios para dividir a maconha em porções individuais.

No armário do quarto, o denunciado guardava dois comprimidos de ecstasy."

Os policiais militares narraram a diligência com riqueza de detalhes.

Paulo Álvaro Ribeiro, policial civil, disse que receberam denúncias de que o acusado traficava naquele prédio e também atuava como Delivery, pessoalmente ou terceirizando a entrega. Fizeram campana e viram movimentação típica de tráfico. Pediram ordem judicial de busca e apreensão e, na posse do mandado, acompanhados do síndico, cumpriram a diligência. Tinha movimentação no imóvel, era possível sentir o cheiro forte de maconha. No local fechado é possível sentir o dor da erva. Ao lado de telefone tinha uma porção. Na cozinha, embaixo de panos de prato em uma gaveta, havia um tijolo de maconha, assim como outras porções iguais aquela que estava ao lado do telefone. Aprenderam, ainda, objetos para embalagem e balança de precisão. Ainda, encontraram mais de mil reais e dois comprimidos de Ecstasy dentro de uma caixinha em seu guarda roupa. Tudo foi registrado por fotografia. O acusado se recusou a dar a senha do aparelho celular. O Delegado tentou a data do seu nascimento e conseguiu, quando constataram diversas transações de drogas (maconha e colombinha, uma maconha melhorada), assim como o acusado segurando grandes quantidades de dinheiro. Ele já era conhecido nos meios policiais, já o prendeu anteriormente por idêntica prática, assim como o pai dele também já foi preso por tráfico. Encontraram uma caixa de entrega de comida, mas sem uso. Não sabe se a tampa estava com alguma avaria, mas parecia nova. Nenhum cheiro de comida e nem mesmo um diálogo de delivery. Pelas conversas, salvo engano, ele adquiria a droga no Saboó e depois revendia. Ele disse que o dinheiro e os comprimidos pertenciam a sua namorada, mas ela não sabia quanto dinheiro havia no imóvel. Ele jamais disse que a droga era destinada ao seu próprio consumo, nem mesmo nas outras prisões que já efetuou.

Rodrigo de Camargo, policial civil, relatou que o acusado já é conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento do tráfico. Denúncias já apontavam seu envolvimento com a venda de drogas naquele endereço e no sistema de Delivery. Realizaram diligências e pesquisas, que confirmavam que realmente se dedicava a esta atividade no período noturno. Ele saiu com isopor do ifood, fazendo a entrega. Fez outra entrega em que um carro escuro parou no prédio. Um funcionário disse que havia uma movimentação atípica, sempre no período noturno. Chegava a receber as pessoas no hall do prédio. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, não permitiram a entrada, puderam ver movimentação por baixo da porta. Houve a necessidade de arrombamento. Na sala, na divisória entre a sala e a cozinha, havia uma porção de maconha. Na cozinha, em uma gaveta, havia mais maconha, faca, rolo de papel filme idêntico as drogas embaladas, balança de precisão operante. Não se recorda se havia panos de prato. No quarto, uma caixa com dinheiro e comprimidos. Um celular foi apreendido, mas ele se recusou a entregar a senha. Na Delegacia de Polícia, depois de diversas tentativas, usaram a data de nascimento e tiveram acesso a diversos

diálogos de comercialização de drogas. Não sentiu qualquer cheiro de maconha antes de entrar no imóvel. A mochila de entrega estava nova, sem manchas ou cheiros. Permaneceram a distância, saindo com uma sacola preta e entregou para a moto e outro dia para um veículo escuro. Estavam distante e não dava para fotografar. Havia algo dentro da sacola. Não encontrou nenhum tipo de contabilidade no local, apenas nas conversas do celular apreendido que aparecia pix referente a recebimento dos pagamentos relativos aos entorpecentes. Nas conversas no celular não havia nenhuma indicação de que o acusado fazia entrega, por delivery, de comida, apenas havia conversas de entrega de entorpecentes por delivery. Com relação ao dinheiro apreendido, ele não falou a origem, a única coisa que falou foi pedir uma oportunidade porque não queria ser preso novamente. Ele já era conhecido nos meios policiais. Em 2018 foi realizada uma investigação, solicitaram um mandado de busca na residência do pai dele, onde ele frequentava, onde encontraram um tijolo de maconha. Participou da investigação, mas na época da diligência do cumprimento do mandado de busca estava de férias. Pelos colegas, tomou conhecimento de que ele não estava no local. Não tem a informação de que o pai dele esteja preso por tráfico, acredita que não.

Com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, “os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador”. (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Rosângela do Nascimento Batista, relatou que é vizinha da mãe do acusado, ele fazia entregas de bolos e doces. Vende doces há um ano e meio. Ele sempre foi pontual. Jamais ouviu comentários que faça entregas de drogas. Os Pix são feitos pelos seus clientes diretamente para a sua conta corrente, ficando responsável pelo repasse a ANDERSON. Ele fazia entregas umas três vezes por semana, dependendo das encomendas, e no período diurno. Pagava entre cinco a vinte reais por entrega, dependendo da região. Fazia o pagamento em dinheiro. Tinha outro entregador nessa função. Conforme a necessidade, pedia ao Anderson para fazer suas entregas. Começou a vender seus doces em abril de 2020 e, por volta de agosto ou outubro, contratou Anderson. Eram entregas esporádicas, pois tem muito cliente que retira pessoalmente. Quando precisava do serviço, contratava Anderson pelo whatsapp dele ou da mãe dele. Ele fazia essas entregas num Biz vermelha, inclusive ele atrasou algumas entregas porque a moto quebrava. Essas entregas eram realizadas de três a quatro vezes por semana e sempre no período diurno.

Anderson Fagundes do Nascimento, em seu interrogatório, negou as acusações que lhe são imputadas. Estava dormindo com a mulher quando escutou um barulho na porta. Após um tempo, os policiais entraram e encontraram um pedaço de maconha que ele tinha para seu próprio consumo. Desde o início declarou ser usuário. A polícia encontrou R\$ 1050,00 (mil e cinquenta reais) reservado para o pagamento de seu aluguel. Os policiais perguntaram qual a senha do celular e informou que era sua data de nascimento tão logo foi detido. Não tinha porções de maconha e a balança encontrada era usada para comida congelada que deixava no congelador. Negou que embalava drogas. Os plásticos eram para embalar alimentos. Disse que comprou 500 (quinhentos) gramas de maconha para fumar o dia todo. Essa quantidade não dura nem um mês, pois faz uso contumaz. Em relação às entregas de bolo, disse que estas variam. Está inscrito no aplicativo de delivery há 3 anos, mas seu lucro mensal não chega nem a R\$2.000,00 (dois mil) reais. Paga R\$ 700,00 (setecentos) de pensão e R\$ 1350,00 (mil trezentos e cinquenta) de aluguel, mas o pai o ajuda constantemente. Estava negociando meio quilo de maconha por R\$ 800,00 (oitocentos), não para fins de tráfico, mas para conseguir um melhor preço e dividir com os amigos. Não entregou nenhuma sacola para as pessoas que o procuravam e falou já conhecer o policial civil Paulo, pois já detido por ele anteriormente.

O acusado, em juízo, negou que a droga apreendida fosse para entrega a consumo de terceiros.

Todavia, sua palavra ficou isolada no contexto probatório, notadamente diante da versão coesa e harmônica dos policiais militares, assim como nenhum elemento de prova permite afastar a usual credibilidade dada aos seus depoimentos, conforme anteriormente mencionado.

Com relação a alegação do réu que a droga se destinava ao seu próprio consumo, importante ressaltar, por oportuno, que os delitos previstos nos artigos 33 e 28, da Lei 11.343/06, restam consumados sempre que a conduta do agente se ajustar, com perfeição, a uma das figuras típicas previstas nestes dispositivos legais.

Seja no tráfico, seja no uso, a conduta do agente de portar o entorpecente restou incontroversa e consumada, restando analisar, apenas, qual o intuito deste porte: o comércio a terceiros ou o consumo próprio.

A comprovação da elementar 'consumo pessoal' exigida pelo tipo do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não é circunstância de fácil constatação, devendo ser balizada pela própria situação fática.

Neste diapasão, ao tratar da antiga legislação, "A COMPROVAÇÃO DA ELEMENTAR DO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 16 - USO PRÓPRIO - NEM SEMPRE É DE FÁCIL CONSTATAÇÃO, PREVENDO A PRÓPRIA LEI, EM SEU ARTIGO 37, ALGUNS CRITÉRIOS LEGAIS. ASSIM, PARA EFEITO DE CARACTERIZAÇÃO DAS CONDUTAS CRIMINOSAS PREVISTAS NA LEI 6368/76, DEVERÃO SER ANALISADOS A NATUREZA E A QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA, O LOCAL E AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, BEM COMO A CONDUTA E OS ANTECEDENTES DO AGENTE. DEVE, IGUALMENTE, SER LEVADA EM CONTA PARA EFEITO DE TIPIFICAÇÃO DO DELITO A FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE". (Legislação Penal Especial - Moraes e Smanio - ed. Atlas, pág. 122).

E ainda, "PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO É INDISPENSÁVEL A PROVA DO ATO DE COMÉRCIO, PODENDO SER ELE DEDUZIDO DE ELEMENTOS VARIADOS COMO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, A QUANTIDADE DO ENTORPECENTE, O LOCAL DA INFRAÇÃO ETC." (TJRJ - Rel. Adolphino Ribeiro - RDTJRJ 20/310).

O acusado foi preso na posse de 0,5 gramas de ecstasy, 580 gramas de maconha (sendo um tijolo e seis pequenas porções), quantidade e forma de embalagem que, evidentemente, são destinadas a facilitar o tráfico, na medida em que usuários da droga, dificilmente, dividem a droga em pequenas porções para o próprio consumo.

Nem mesmo trouxe aos autos provas de uma ocupação lícita que lhe permita gastar com mais oitocentos reais com maconha, já que sua testemunha de defesa disse que chama o acusado esporadicamente, quando há excesso de pedido e seu motoboy não da conta de todas as entregas no período diurno.

Destaco, por fim, que não foi reconhecida a dependência química do acusado em incidente próprio, que, ao tempo da ação, era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito da sua conduta e de se autodeterminar.

No mesmo caminho trilha a jurisprudência: "CARACTERIZA O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE TRAZER CONSIGO, SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR, MACONHA E CLORIDRATO DE COCAÍNA, EM DOSES UNITÁRIAS, DE PEQUENOS EMBRULHOS, EMBALAGEM USUAL DO VAREJO DAS DROGAS". (TJRJ - Rel. Enéas Machado Cotta, RDTJRJ 23/288).

"IDENTIFICANDO O FORNECEDOR DAS SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, EM PODER DE QUEM FOI

APREENDIDA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE COCAÍNA, PARTE JÁ DIVIDIDA EM DEZENAS DE PAPELOTES, PRONTOS PARA ENTREGA A CONSUMO, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO, SEM QUE SE POSSA, TODAVIA, RECONHECER ASSOCIAÇÃO COM COMPRADORES". (TJRJ - Rel. Paulo Gomes da Silva Filho - RDTJRJ 20/313).

Assim, a apreensão de quantidade significativa de entorpecente e que não se amolda à postura de usuários, é meio de prova, um indício e não uma presunção, indício que, corroborado com outros elementos de prova como o laudo das conversas do WhatsApp comercializando drogas e a falta de ocupação rentável que lhe garanta a aquisição daquela droga para satisfazer o vício, ao menos pelo padrão invocado em audiência.

Não obstante ele mesmo reconhecer que seus ganhos não superaram dois mil reais com entregas, foi apreendido em sua residência a quantia de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais) que pretende convencer que era destinado ao pagamento do aluguel e que tem a ajuda do seu pai. E, na mesma diligência, apreenderam, ainda, uma balança de precisão, uma faca de cozinha, uma bandeja, um rolo de película filme, dois sacos de papel, uma mochila térmica de entregador de pizza, tudo demonstrando sua atividade no comércio delivery de tráfico de entorpecentes.

Embora diga ser cadastrado no sistema de Delivery há três anos, sua caixa de mochila para entrega, durante a campanha dos policiais, não ostentava qualquer bandeira do serviço prestado, como se depreende do relatório de investigação (fls. 31 dos autos em apenso).

Os investigadores fizeram campanha e observaram que o acusado era solicitado por diversos jovens durante o período noturno na portaria do seu prédio, jovens aparentemente de classe alta pelo carros em que chegavam, que permaneciam por curto período e iam embora com algo nas mãos.

Um motoqueiro com mochila de entrega, sem qualquer identificação do serviço, estacionou na portaria e o acusado desceu e lhe entregou uma pequena sacola preta, ausentando-se rapidamente (fls. 05), assim como funcionários do prédio confirmaram acerca da intensa movimentação noturna a procura do acusado, incompatível com um prédio residencial.

Ainda, pelo laudo pericial realizado no celular apreendido na posse do réu, apreendido no momento de sua abordagem no local dos fatos, consta imagens onde o réu aparece com grande quantidade de dinheiro em notas de cinquenta reais - foto tirada dentro do Conjunto Habitacional BNH, palco de constantes operações para coibir o forte tráfico de entorpecentes (fls. 242/243), com grande quantidade de droga idêntica aquela apreendida, assim como as várias transações bancárias realizadas e diálogos que não deixam dúvidas acerca do objeto comercializado por delivery (fls. 211/279).

Tais elementos permitem a condenação do réu, porquanto permitem crer que seu destino era a entrega a consumo de terceiros pelo sistema de Delivery, um incremento da atual comercialização de drogas e que tem dificultado o enquadramento do motoboy eventualmente detido como traficante pelas reduzidas porções transportadas, assim como mantém usuário e traficante distantes, longe de um cenário conhecido como ponto de tráfico pela polícia, por vezes alvo de denúncia anônima por vizinhos.

O trabalho de investigação da polícia foi preciso, mormente quando o acusado já era figura conhecida dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de entorpecentes e as conversas do WhatsApp, com ofertas no sistema Delivery, confirmam sua dedicação a atividade criminosa.

A inviolabilidade do sigilo das correspondências e das comunicações telefônicas não se confunde com os dados obtidos após regular inspeção no aparelho que os armazenava, seja com autorização do réu confirmada em audiência, seja com desbloqueio tecnológico com autorização judicial.

Com relação ao sigilo das comunicações, prudente destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SIGILO DE COMUNICAÇÕES. APLICATIVO INSTANTÂNEO DE CONVERSAS (WHATSAPP). ACESSO FRANQUEADO PELO USUÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL NÃO VIOLADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 3. Durante a abordagem policial, o paciente estava usando o aparelho de telefonia celular, quando uma mensagem de áudio foi ouvida pelos policiais. Em seguida, o próprio paciente franqueou o acesso dos milicianos ao conteúdo do seu telefone, conforme se extrai dos autos. 4. A situação retratada nos autos não se encontra albergada pelo comando do art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal, o qual assegura a inviolabilidade das comunicações, ressaltando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida pela Lei n. 9.296/1996, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 5. Habeas corpus não conhecido." (HC 542637/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 19/12/2019 g.n.).

"(...) 3. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida (AgRg no HC PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Criminal nº 1510810-23.2021.8.26.0228 -Voto nº 593 9 391080/SC, rel. Ministro Nefi Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017). 4. Ordem de habeas corpus denegada." (HC 468968/PR, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20/05/2019 g.N.

Diante do exposto, é imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecentes prescrita pelo artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosimetria da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do acusado, que não desdobrou o dolo mínimo necessário para a configuração do delito, os maus antecedentes devidamente certificado (fls. 537/541) e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força da reincidência específica devidamente certificada (fls. 537/541), aumento a pena em 1/5 (um quinto), totalizando na reprimenda de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa.

O unitário do dia-multa foi fixado no mínimo legal tendo em conta as condições econômicas da ré que, ao que consta, não goza de um elevado padrão de vida, razão pela qual se faz necessário fixar o unitário em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Em razão do caráter hediondo da conduta perpetrada e a reincidência específica do réu, o regime de cumprimento da pena será o inicialmente fechado.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e CONDENO o réu anderson fagundes do nascimento, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, calculados, unitariamente, no mínimo legal, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", da

Lei 11.343/06.

A alteração levada a efeito no § 2º, do art. 387 do Código de Processo Penal, no tocante ao instituto da detração, é de duvidosa constitucionalidade, por aparente violação dos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e da isonomia (art. 5º, caput, CF/88).

O merecimento do condenado integra os requisitos para sua promoção de regime, sendo crucial à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugere uma interpretação mais superficial do novo § 2º, do art. 387, do Código de Processo Penal, dependendo do preenchimento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos.

A reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do Código Penal, de tal sorte que a fixação de regime inicial ainda deve considerar obrigatoriamente, além da pena aplicada, se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal.

Em razão do exposto, o desconto da pena cumprida pelo acusado deverá ser mesmo apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois ele permaneceu preso durante toda a instrução processual, devendo, pois, continuar recolhido após a prolação da sentença condenatória, já que, se antes mesmo do julgamento do mérito ele estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação, pois: "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais" (RT 504/339).

Consoante já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória". (RHC 177 - RJ - 5ª Cam. Do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89.)

Após o trânsito em julgado:

1. Preencha-se o boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de Identificação Criminal (art. 809 do CPP).

2. Comunique-se o deslinde do feito ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, III, da Magna Carta de 1988.

3. Proceda-se o cálculo da pena de multa, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Após, intime-se o réu para o seu pagamento dentro de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 50 do CP.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no montante de 100 (cem) UFESP's, com base no contido no art. 4º, § 9º, alínea "b", da Lei nº. 11.608/2003, observando-se, se for o caso, o contido no art. 12 da Lei nº. 1.060/50.

Determino a incineração da substância entorpecente apreendida, mediante auto circunstanciado, nos termos do art. 32, § 1º, da Lei nº. 11.343/2006 e a perda da quantia apreendida em favor da União.

P.I.C.

Santos, 26 de julho de 2022.

LUCIANA CASTELLO CHAFICK MIGUEL
Juíza de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA